

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/3699

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור על עינויים ועל יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 277א¹. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 277 יבוא:

"עינויים 277א. (א) בסעיף זה –

"יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל" – מעשה הנעשה על ידי עובד הציבור, מי שממלא תפקיד רשמי, או באישורו, בידיעתו, בשידולו או בהסכמתו שבשתיקה ואשר גורם לאדם כאב או סבל אשר אינם עולים כדי עינויים;

"מענה" – אדם המבצע עינויים;

"עינויים" – מעשה הנעשה על ידי עובד הציבור, מי שממלא תפקיד רשמי, או באישורו, בידיעתו, בשידולו או בהסכמתו שבשתיקה ואשר גורם לאדם במכוון כאב או סבל חמור, גופני או נפשי, למעט כאב או סבל הנובעים מעונשים או מעיצומים המוטלים על פי חוק, וזאת –

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(1) במטרה להוציא מאותו אדם או מאדם אחר מידע או הודאה, להענישו על מעשה שהוא או אדם אחר ביצע או נחשד בביצועו, או כדי להפחידו או להפחיד אדם אחר;

(2) מכל סיבה אחרת הכרוכה בהפליה מחמת גזע, דת, קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין או נטייה מינית.

(ב) המענה, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

(ג) המענה וגורם בכך לחבלה חמורה, דינו – מאסר עשרים שנים.

(ד) המענה וגורם בכך למוות, דינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד.

(ה) עובד הציבור שידע כי נעברה עבירה של עינויים ולא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את ביצועה, דינו כדין המענה.

(ו) עובד ציבור או מי מטעמו, בהוראתו, באישורו בשידולו או בידיעתו, הנוקט כלפי כל אדם ביחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל, או מטיל עונש העולה כדי יחס כאמור, דינו – מאסר שבע שנים.

(ז) הוראות סעיף זה יחולו על כל אדם שהיה בעת ביצוע המעשים עובד ציבור או ממלא תפקיד רשמי, או עובד מטעם המדינה, או מי מטעמם, בין אם המעשים בוצעו בתוך שטחי מדינת ישראל ובין אם בשטחים אשר בשליטתה.

(ח) אין בקיומו של מצב חירום, לרבות מלחמה, חשש מאי-יציבות ביטחונית או פוליטית, או קיומו של חשש להתרחשות מצבים כאמור, כדי להצדיק חריגה מן האמור בהוראות סעיף זה.

(ט) הוראות סעיפים 34א, 34ב, 34ג לא יחולו לגבי עבירות לפי סעיף זה."

דברי הסבר

עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל פוגעים פגיעה קשה וחמורה בכבודם, בנפשם ובגופם של בני אדם ומטרתם היא לשבור את רוחו ונפשו של הקורבן. עינויים ויחס מן הסוג האמור עלולים לגרום להשלכות פיזיות, נפשיות ותפקודיות קשות. בשל כך, לאיסור על עינויים שמור מקום מיוחד במשפט הבינלאומי. מדובר באיסור מוחלט, אשר אין לחרוג ממנו או לאזן אותו אל מול איסורים אחרים, ולא ניתן לפגוע בו אף בעתות מלחמה, אי יציבות פוליטית או נסיבות חריגות אחרות. האיסור חל במסגרת הפעלת סמכויות המדינה כלפי אזרחיה וכלפי אנשים אחרים אשר נמצאים תחת שליטתה והחזקתה.

האיסור על עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל מהווה נורמת יסוד משפטית. האיסור מופיע בסעיף 5 להכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות אדם משנת 1948. כמו כן, הוא מעוגן באמנות זכויות אדם, במשפט הבינלאומי ההומניטארי ובמשפט הפלילי הבינלאומי. האיסור אף מהווה דין מנהגי ולפיכך מחייב את כל המדינות. במשפט הישראלי הוכר האיסור המוחלט על נקיטת עינויים ויחס אכזרי בבג"ץ 5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל. שם נקבע כי "ראשית, חקירה סבירה היא חקירה ללא עינויים, ללא יחס אכזרי או בלתי אנושי כלפי הנחקר וללא יחס משפיל כלפיו... כבוד האדם הוא גם כבודו של האדם הנתון לחקירה... מסקנה זו עולה בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי ההסכמי – אשר ישראל צד לו – האוסר על שימוש בעינויים ב"יחס אכזרי, לא אנושי ומשפיל". איסורים אלה הם מוחלטים. אין להם חריגים, ואין בהם איזונים."

לאחרונה חזר על כך בית המשפט העליון בבג"ץ 5512/12 אסעד אבו גוש נ' היועץ המשפטי לממשלה: "אכן, בשיטתנו המשפטית קיים איסור מוחלט על השימוש בעינויים."

ב-22 באוקטובר 1986 חתמה מדינת ישראל על האמנה הבינלאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (להלן "האמנה נגד עינויים"). ביום 4 באוגוסט 1991, אושרה האמנה על ידי מדינת ישראל והיא נכנסה לתוקף. בעשותה כן, התחייבה המדינה לנקוט באמצעים יעילים תחקיקתיים, מנהליים, משפטיים או אחרים למניעת עינויים בכל שטח שבסמכותה השיפוטית ולהבטיח כי עינויים יהיו עבירה על פי הדין הפלילי המדינתי (סעיפים 2,4 באמנה נגד עינויים, וכן סעיפים 146-147 לאמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בימי מלחמה משנת 1949).

מדינת ישראל הכירה בחשיבות עיגון עבירת העינויים זה מכבר, אם על ידי גופי הממשל השונים או ועדות רשמיות מטעם הממשלה. כך, ביום 06.02.13, פורסם חלקו השני של דוח ועדת טירקל לבדיקת אירוע המשט הימי מיום 31 במאי 2010 בנושא "מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי", ובו המלצות הוועדה לעניין מנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות בדבר הפרות של דיני הלחימה. בהמלצות הראשונות בדו"ח, קובעת הוועדה כי יש ליזום השלמת חסרים בחוק הפלילי הנוגעים לאיסורים בינלאומיים להם מדינת ישראל מחויבת. הוועדה מתייחסת ספציפית לעיגון האיסור על עינויים בחוק הפלילי הישראלי ומציינת: "...יש לוודא שהאיסור המוחלט במשפט הבינלאומי על עינויים והתעללות נקלט כהלכה לדין הישראלי. זאת, על מנת לאפשר 'ענישה פלילית אפקטיבית' של מי שמבצע פשעי מלחמה, כנדרש על פי הדין הבינלאומי. בנוסף לאמור, הוועדה רואה חשיבות בקליטה מפורשת של הנורמות הבינלאומיות לגבי פשעי מלחמה למשפטה של

מדינת ישראל". בהמשך, בדוח שהוגש על ידי הצוות הבין-משרדי לבחינת יישום המלצות דוח ועדת טירקל מחודש יוני 2016 (להלן – דוח צ'חנובר), פורסם כי היועץ המשפטי לממשלה הורה לממשלה לגבש טיוטת תזכיר חוק בעניין עיגון עבירת העינויים בחוק העונשין הישראלי וכי "עבירת העינויים שתעוגן צפויה לקבוע איסור, ברוח עבירת העינויים שבאמנה נגד עינויים, שעניינו גרימת כאב או סבל חמור, בין גופניים ובין נפשיים, על ידי עובד ציבור במטרה להוציא מאדם מידע או הודאה, לסחוט אותו וכיוצא באלה תכליות שיוגדרו בחוק... צוות היישום המליץ כי משרד המשפטים יפעל בהקדם להמשך קידום חקיקה לעיגון עבירת העינויים בחוק העונשין." (דוח צ'חנובר, בעמ' 9-10).

בחודש מאי 2016, הצהירו נציגי המדינה בפני ועדת האו"ם נגד עינויים כי בכוונת המדינה לחוקק את עבירת העינויים בחוק העונשין וכי החל הליך ניסוח הטיוטה במשרד המשפטים. בעקבות זאת, ביוני 2016, פרסמה ועדת האו"ם נגד עינויים את המלצותיה הנוגעות למילוי התחייבויותיה של מדינת ישראל על פי האמנה נגד עינויים. בסעיפים 12-13 למסקנות הוועדה, צוין כי הוועדה מודאגת מכך שטרם אומצה עבירה ספציפית של עינויים בישראל והיא קוראת למדינה לנקוט בצעדים הדרושים על מנת להאיץ את התהליך לשילוב עבירה שכזו בחוק הפנימי, תוך כדי שהיא מבטיחה כי העבירה תואמת באופן מלא את הגדרת העינויים כפי שמופיעה באמנה (Committee against Torture, Concluding observations on the fifth periodic report of Israel, [adopted by the Committee at its fifty-seventh session 18] April-13 May 2016 (United Nations CAT/C/ISR/CO/5)). אף בתכנית העבודה של משרד המשפטים לשנים 2017–2018 פורסם כי המשרד שם לו למטרה לעגן את עבירת העינויים שבאמנה נגד עינויים בחוק העונשין (משרד המשפטים, תכנית עבודה לשנים 2017-2018, בעמ' 9-10). בדיווח שהגישה ישראל לאמנה נגד עינויים בשנת 2020, נמסר כי עבודת ההכנה על החוק נגד עינויים "עודנה נמשכת". בשנת 2022 העירה הוועדה כי על ישראל לחוקק חוק זה ללא דיחוי נוסף.

מבקר המדינה התייחס אף הוא להצהרות המדינה בנושא בדו"ח הנוגע לפעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבינלאומי (מבקר המדינה, "מבצע צוק איתן", פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאי", אדר התשע"ח, מרץ 2018, פורסם ביום 14.3.2018). מבקר המדינה חזר על הנאמר בדוחות טירקל וצ'חנובר וציין כך: "בספטמבר 2016 מסר היועמ"ש לממשלה למשרד מבקר המדינה בתגובתו על טיוטת הדוח כי "טיוטות התזכירים בעניין עבירת העינויים וחוק פשעים נגד האנושות הוצגו לי בדיון שהתקיים בראשותי ביום 8.8.16 ואושרו על ידי, בכפוף להמשך העבודה עליהן במספר נקודות. טיוטת התזכיר בעניין עבירת העינויים תוצג בזמן הקרוב לשרת המשפטים וככל שיינתן אישורה, יופץ התזכיר." משרד מבקר המדינה העיר בדוח למשרד המשפטים "כי נוכח חשיבות הכללת עקרונות המשפט הבינ"ל בדין הישראלי, עליו לזרז את קידום החקיקה בעניין זה, זאת כדי לשפר את ההלימה בין החקיקה הישראלית לדין הבינ"ל ולוודא כי היא כוללת את כל העבירות הרלוונטיות להגדרה כפשעי מלחמה" (שם, בעמ' 70-71).

סעיף 277א(א) המוצע מאמץ את הגדרת המושג עינויים כפי שנקבעה בסעיף 1 לאמנה נגד עינויים. הגדרה זו מפרטת מיהו המענה ומהם המעשים העולים כדי עינוי. באמנה נגד עינויים, המונח "עינויים" מוגדר כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב או סבל חמור, בין אם פיזי, בין אם מנטלי, במטרה להוציא ממנו או מאדם אחר מידע או הודאה, להענישו על מעשה שביצעו או נחשד בביצועו, הוא

או אדם אחר, או להפחיד או לאנוס אותו או אדם אחר; או מכל סיבה ששורשיה בהפליה מכל סוג שהוא, מקום שכאב או סבל כאמור נגרמים בידי או באישור או בהסכמה בשתיקה של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי בשידולו, אין הוא כולל כאב או סבל הנובעים מעיצומים על-פי חוק, טבועים בהם או נלווים אליהם".

המונח "כאב או סבל חמורים" המופיע בסעיף, ייבחן, כמקובל, על פי מאפייניו המסוימים של כל מקרה ומקרה, בהם: אופי המעשים, אופי הפגיעה, מאפייני הקורבן (דוגמת גיל או מין) והנסיבות בהן בוצעו המעשים. יחד עם זאת, ישנן שיטות עינויים מסוימות שגורמות לכאב או סבל חמור באופן בלתי נמנע, אלה כוללות בין היתר: נקיטה באלימות פיזית, החזקה בתנחות כואבות, הטרדה מינית, איזוק מכאיב, איומים, החזקה בבידוד תוך מניעת קשר עם החוץ, הפחדה והפעלת לחץ נפשי ופיזי. אין זה הכרחי כי מעשה העינוי יהיה מעשה של אלימות פיזית או נפשית ישירה. עינוי יכול להתבטא גם במניעת גישה לצרכים בסיסיים מן האדם כגון: מזון, שינה ואף מניעת יציאה או גישה לשירותים.

מבצעי עבירת העינויים הם עובדי ציבור, או ממלאי תפקיד רשמי (או מי מטעמם), אשר מתוקף תפקידם נקטו בעינויים או יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל.

סעיפים 277א(ב)–(ה) קובעים את העונשים הצפויים למבצעי העבירה, לשותפים לביצוע, ואת חומרת העונש בהתאם לתוצאת העינוי. העונש הקבוע לעבירת העינויים הוא חמש עשרה שנות מאסר. עונש זה תואם את חומרת העבירה ואת האיסור המוחלט אותו היא משקפת. עונשו של המענה יוחמר לעשרים שנות מאסר באם מעשה העינוי הוביל לגרימת חבלה חמורה. במידה והמעשה הוביל למוות, יהא העונש מאסר עולם חובה.

סעיף 277א(ו) המוצע מאמץ את הוראות סעיף 16 לאמנה נגד עינויים, וקובע כי החובות המוטלות על המדינה באשר למעשי העינויים יחולו גם כאשר מדובר ביחס או עונש אכזרי, בלתי אנושי או משפיל. הביטוי "יחס או עונש אכזרי, בלתי אנושי או משפיל" מוגדר באופן שיורי, בהתאם לסעיף 16 לאמנה נגד עינויים אשר אוסר על מעשים אחרים של יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל, אשר אינם עולים כדי עינויים, כאשר מעשים אלו נעשים על-ידי עובד ציבור, בידעתו, בשליחותו או בידעתו כמוגדר בחוק זה. לפי פסיקת בית הדין האירופאי לזכויות אדם, השאלה אם מעשה מסוים חוסה תחת האיסור על יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים מחייבת מידה מינימלית של חומרה, והיא נבחנת ממקרה למקרה, ואולם תנאי כליאה קשים, חשיפה לחום או קור קיצוניים, תאורה בלתי פוסקת, תנאי העברת אסירים ועצורים ממקום למקום, תנאי אשפוז, תנאים סניטריים ייחשבו ככלל ליחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל (ר' למשל *Selmouni v. France* (1999). European Court of Human Rights). עוד יצוין, כי מעשים מסוג אלו, אם יבוצעו באורח קיצוני, או אם יתווספו למעשים נוספים ויבוצעו כלפי אותו אדם, יכולים לעלות לכדי עינויים ולחסות תחת הוראות סעיפים 277א(ב)–(ה).

סעיפים 277א(ז)–277א(ח) המוצעים מאמצים את הוראות סעיף 2 לאמנה נגד עינויים באשר לאופיו המוחלט של האיסור על עינויים. סעיף קטן (ז) קובע את תחולת העבירה על פי הוראות סעיף 5 לאמנה נגד עינויים. סעיף קטן (ח) מדגיש כי לא ניתן להצדיק ביצוע עינויים או שימוש ביחס אכזרי בלתי אנושי או משפיל, או לתלותו בעובדת קיומו של מצב חירום/מלחמה, או אי יציבות כלשהי פנים מדינתית או חוץ מדינתית בהתאם לסעיף 2 לאמנה נגד עינויים.

סעיף קטן (ט) נועד אף הוא להבטיח כי האיסור על עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל יהא מוחלט, כך שהגנות המשפט הפלילי (הגנת הצורך, הכורח והצידוק) לא יחולו כלפי עבירה זו. הוראה זו עולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי והוראותיה המפורשות של האמנה נגד עינויים. חשיבות סעיף זה רבה ביותר, שכן השארת ההגנות הקבועות בחוק העונשין והשימוש בהן ובייחוד בהגנת ה"צורך", תותיר את האיסור ריק מתוכן. יש לקבוע קביעה חד משמעית וברורה כי מעשי העינויים ויחס אכזרי אסורים בכל מצב. יצוין כי בכל הנוגע לחקירות שב"כ, נקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה כבר בשנת 1999, כי "הגנת הצורך" לא תחול על "אמצעי שנקיטתו היא בגדר "עינויים", כמשמעות באמנה נגד עינויים ונגד יחס משפיל ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים". התיקון המוצע מרחיב את האמור בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה וקובע כי הגנות חוק העונשין לא יעמדו גם לנאשם בנקיטת יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל.

יצוין כי מן הראוי היה לחוקק חוק עצמאי נגד עינויים אשר יקיף את כל ההיבטים העולים מתוך התנהגויות נפשעות אלו. האמנה נגד עינויים מפרטת הוראות נוספות אשר עוסקות בהיבטים של שיקום הקורבנות, שלילת חסינויות וחנינות למבצעי העבירה, החרגת העבירה מעקרון ההתיישנות ואיסור החזרת הקורבן למקום בו בוצעה העבירה. אולם בשל הדחיפות הקיימת בעיגון איסור זה בחוק הפנימי של מדינת ישראל ובשל השיהוי הרב בהכנסתו לדין הישראלי, מוצע בזאת תיקון לחוק העונשין בלבד. אשר על כן, באין טיוטת תזכיר חוק ממשלתית נגד עינויים, ובשל החשיבות הרבה של הוספת עבירה נגד עינויים לחוק העונשין הישראלי, זאת במטרה להגן ולשמור על כבודם וחירותם שלמות גופם ונפשם של בני האדם, ועל מנת להרתיע מפני ביצוע מעשים כה נפשעים, ואף למען מילוי התחייבויותיה של מדינת ישראל כלפי הקהילה הבינלאומית, מוגשת הצעת חוק זו.

הצעת חוק זו נוסחה בסיוע הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)